

1500206-86.2021.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Humberto Isaías Gonçalves Rios

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e uma faca, ambas com resquícios de tóxico (fls.97/99).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500206-86.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-86.2021.8.26.0556

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2078901/2021 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 16903801 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

499/21/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2078901 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA,

499/21/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIAN PEREIRA BORGES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Isaías Gonçalves Rios

Vistos.

CRISTIAN PEREIRA BORGES está sendo processado pela Justiça Pública, por incurso nas penas do art. 33, "caput", c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c o art.61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, como narra a peça inicial, aos 20 de março de 2021, por volta das 19:10 horas, durante o estado de calamidade pública (Decreto Legislativo n. 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20 de março de 2020), na Av. Comendador Alberto Dias, n. 1500, Jd. Tangará, nesta cidade, estaria trazendo consigo, mantendo em depósito e vendendo, para fins de tráfico, 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 17,76 gramas, o que

fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, tratando-se de substância que causa dependência física e psíquica, contando da lista daquelas de uso proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS n. 344/98, conforme laudos de fls.17/19 (constatação) e fls.92/94 (toxicológico). A denúncia veio instruída com rol de três testemunhas (fls.134/137).

A seguir, a inicial acusatória foi recebida (fls.138/140).

Por decisão de fls.39/43 o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, sendo, na sequência, concedida a ordem de habeas corpus para determinar a soltura do acusado, beneficiado pela liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP (fls.154/160).

Expedido o alvará de soltura (fls.162/163), o seu cumprimento adveio a fls.185/188. O réu foi citado (fl.205) e apresentou resposta à acusação (fls.208/211), acompanhada de documentos (fls.212/223).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls.229/230), designando-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls.233/234).

Durante a audiência foram ouvidas quatro testemunhas, sendo, ao final, interrogado o réu (fls.279/283).

Na mesma oportunidade, pelo Dr. Promotor de Justiça foram apresentadas alegações finais orais, requerendo a parcial procedência da ação para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, com a exclusão da causa de aumento de pena por não restar demonstrada. Pede a exasperação da pena-base e o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de drogas, além da fixação do regime fechado para fins de cumprimento (fls.280/283).

O Dr. Defensor, por sua vez, manifestou-se através de memoriais (fls.284/291), suscitando, preliminarmente, a inobservância ao princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, acarretando a ilicitude da prova. Quanto ao mérito, argumenta que o réu é dependente químico, circunstância não infirmada pelo restante da prova oral, tendo-se a ausência de elementos probatórios do comércio de tóxicos por ele. Salienta, ademais, inexistir no caso trabalho investigativo prévio, postulando a absolvição com fulcro na fragilidade probatória ou ainda a desclassificação da conduta para aquela prevista do art.28 da Lei 11.343/06.

Sucessivamente, roga pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da mesma lei, assim como da agravante que constou da denúncia, além do enquadramento na figura do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a imposição do regime aberto.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar levantada pela defesa, não sendo o caso de nulidade da ação policial e das provas dela derivadas.

Para se falar em violação do direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio necessário seria que nos autos houvesse elementos para se afirmar que o ingresso no domicílio do réu está acobertado sob o manto da ilicitude. No caso em apreço, todavia, isso não se evidenciou. De acordo com os policiais, o acesso foi franqueado, inclusive pela genitora do acusado, sendo o comparecimento à residência motivado em fundadas razões, provenientes de contexto fático anterior, no qual o comércio de droga ilícita foi confirmado, para além do caráter permanente do delito. Outrossim, os documentos de fls.100/109, que chegaram ao conhecimento dos policiais, dizem respeito a anúncios divulgados pelo réu nas redes sociais ofertando entorpecente para venda, de modo que as circunstâncias do caso concreto e as sólidas suspeitas da ocorrência do crime no interior do imóvel abonaram a ação imediata da polícia. Esta, aliás, resultou no encontro de dinheiro escondido em uma TV, maconha e instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e uma faca, ambas com resquícios de tóxico (fls.97/99).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência”. (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,

DJe de 10/05/2017).

E ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Neste caso, o contexto fático delineado nos autos demonstra que o contexto fático antecedente permitiu que os policiais concluíssem pela necessidade de realizar buscas do domicílio do acusado, ante a presença forte de indícios da prática criminosa, de maneira que a adoção da medida encontra-se justificada, diante da presença de fundadas razões da ocorrência de crime 3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no HC n. 737.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022). g.n.

Nessas circunstâncias, portanto, não se verifica abuso policial ou a deliberada invasão da residência do acusado, impondo-se a rejeição da preliminar. No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou inconteste (fls.09/11, 12/14, 17/19, 92/94, 97/99, 100/109).

A prova oral coligida aos autos evidenciou que o acusado trazia, bem como mantinha em depósito a substância entorpecente, para fins de comércio, inclusive exercido por ele momentos antes da abordagem.

Os policiais militares Luiz Carlos Fernandes Gouvea Junior e Maxwell Dias da Silva disseram, em juízo, que realizavam patrulhamento pelo bairro e tinham informações de que um indivíduo, de nome Cristian (réu), realizava o tráfico de drogas através de redes sociais e do chamado "disk entrega", levando a droga até as pessoas com o seu veículo, um FIAT/Stilo. Passavam pelo endereço dele quando avistaram três pessoas, que ao perceberem a presença da viatura, deram um toque para aquela que achava dentro do carro, a saber, o denunciado. Alegaram que essa atitude suspeita de um ficar querendo avisar ao outro sobre a aproximação da viatura policial chamou-lhes a atenção. Fizeram a abordagem do trio e, em busca pessoal, com Ivando foi localizada uma porção de maconha acondicionada em um saquinho zip lock, tendo ele dito que comprou a droga do réu, pagando R\$10,00. Este, por sua vez, negou qualquer relação com esse entorpecente, dizendo ser usuário. Contaram, também, que durante a revista veicular localizaram a quantia de R\$10,00, destacando que o carro do réu era o mesmo que lhes foi descrito como sendo o que era utilizado para as entregas de drogas, sendo que o referido valor coincidia com aquele declarado, momentos antes, por Ivando como pago ao réu. Indagaram ao acusado sobre a existência de mais drogas, o que foi por ele negado, arguindo que poderiam entrar na sua residência. Foram até lá, ocasião em que a mãe dele foi chamada e colocada a par dos fatos, bem como da denúncia existente contra o filho e sobre o grupo chamado "Araraquara em chamas", onde circulavam fotos do acusado com drogas nas mãos e "ofertando que hoje está para negócio", ficando ela "espantada" nas palavras do policial Maxwell e "abismada" nas do policial Luiz Carlos, vez que viu que era mesmo o réu nas fotografias. Descreveram que, então, entraram no imóvel com a autorização da genitora e do denunciado, a qual foi colhida por escrito, cuja juntada não lhes foi solicitada, havendo, igualmente, filmagens, oportunidade em que encontraram no quarto deste um frasco com medidor e um pouco de farelo de maconha em cima de uma penteadeira. Prosseguiram com as buscas, que culminaram com a descoberta de uma faca, que foi apreendida e continha resquícios de maconha, assim como de um tablete da mesma substância ilícita prensada de acordo com o depoente Luiz Carlos, a qual foi descrita como uma porção por Maxwell, além de uma balança de precisão e da importância de R\$450,00, em dinheiro. Quanto a esta, estava oculta em uma TV que se achava em um suporte, a qual o genitor, que nesse instante acompanhava a diligência, desconhecia, relevando os policiais que o réu assumiu pertencer-lhe, sem, porém, informar a origem. Ainda segundo o policial Maxwell, os pais do réu negaram que deram a ele o referido montante, ratificando

que a sua procedência não foi informada pelo mesmo. Disseram que o acusado admitiu, igualmente, a propriedade do tóxico apreendido. Não o conheciam. Colhe-se, além disso, que o denunciado citou aos policiais que é dependente e que vendia a droga para sustentar o seu vício, acrescentando a testemunha Maxwell que ele explicou que comprava uma porção grande e fracionava, parte destinando ao uso e parte para a venda, bem como que declarou que não fazia isso sempre. As testemunhas também relataram que acharam plástico filme e saquinhos zip lock na residência, parte destes junto com a faca com resíduos da droga, os quais eram iguais ao entorpecente que foi apreendido na posse de Ivando. Frisaram que este confirmou tê-lo adquirido do réu, mas que não visualizaram a transação. Tanto Ivando como o acusado foram encaminhados para a delegacia, apresentando-se a ocorrência. No mais, exibidas as fotografias a fls.100/109 do processo ao policial Maxwell, este ratificou se tratar das mesmas imagens que recebeu sobre a denúncia, levada ao conhecimento do seu superior (00'20'' até 11'54'' e 12'20'' a 27'42'').

A testemunha Ivando Lourenço da Silva disse ser amigo do réu, conhecendo-o há cerca de quatro anos. Expôs que estavam bebendo, encontrando-se no local, além dos dois, outro amigo chamado Fernando. Mencionou que a polícia entrou na casa do acusado, de quem negou ter adquirido a droga, argumentando que a compra desta ocorreu na rua, tratando-se de um cigarro de maconha, pego pelos policiais. Aduziu que estes não agrediram ninguém, não sabendo se encontraram algo no imóvel porque ficou do lado fora. Foi para a delegacia, onde prestou depoimento e contou o que aconteceu. Não sabe o porquê no seu depoimento consta outra coisa, arguindo que não o leu e que pediram que o assinasse. Não conhece os policiais e na delegacia não teve entreveio. Já foi preso anteriormente e possui um processo por tráfico de drogas em andamento (28'08'' a 35'40'').

A testemunha Rafael Henrique da Rocha disse que conhece o réu há oito, quase dez anos aproximadamente, sendo seu amigo. Sabe que ele fuma baseado, explanando que o viu uma vez consumindo maconha, de modo que tem conhecimento de que o réu usa tal droga. Desconhece o envolvimento do acusado com o tráfico ou venda de entorpecentes, sabendo que este trabalha com entregas, inclusive pelo ifood, atividade que exerce faz um bom tempo, estimando-o em quase quatro anos. Não conhece Ivando. (43'50'' a 46'10'').

Finalmente, o réu, em seu interrogatório judicial, negou a acusação, dizendo que possui apenas este processo criminal e que trabalha com entregas. Sobre os fatos, alegou que estavam lavando o carro e bebendo no local, bem como que fumavam maconha e achava-se no banco do passageiro. Narrou que os R\$10,00 seriam o troco da compra da droga que apanharam e que aquela apreendida em sua casa era pouca e para o seu próprio consumo, aludindo que comprou a balança de precisão para pesar o entorpecente que adquire e conferir se não está faltando. Já o dinheiro provinha das entregas, juntando-o com R\$150,00 que ganhou da sua mãe. Nunca tinha visto os policiais e tampouco tinha problemas com eles, admitindo-lhes que era apenas usuário. Colocava a droga no vidro/frasco para conservá-la, aduzindo que guardava o seu dinheiro atrás da TV e que os saquinhos zip lock utilizava para colocar porções menores do tóxico quando fosse fumar na rua. Sobre as publicações em redes sociais, citadas pelos policiais, disse recordar somente daquelas em que aparece fumando maconha, o que faz constantemente, igual a cigarro, durando a droga dois dias consigo. É dependente de maconha, a qual consome desde os 14 anos, mas não passou por tratamento porque não acha ela lhe faz mal. Não consome outros tipos de entorpecentes. Tinha o costume de fumar maconha com os meninos, como Ivando. Mencionou que os policiais não conversaram consigo para desse autorização para a busca domiciliar. (46'20'' a 57'57'').

Percebe-se, então, que a prova oral produzida foi apta a incriminar o denunciado, mormente porque respaldada pela apreensão do entorpecente, dinheiro e outros materiais comumente empregados para o preparo e colocação da droga para venda a outros dependentes químicos.

Os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos. Reserva alguma há de se impor, "in casu", aos seus testemunhos, como reiteradamente decidido, "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT, vol.616/287); no mesmo sentido: RT, vols. 433/386; 445/384; 479/382; 634/276; RJTJESP, ed. LEX, vols. 95/400; 107/457 e 189/328; JUTACrim, vols. 8/24; 67/369; 76/331.

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. Outrossim, segundo decidiu o STJ, no AgRg no AREsp 1698767/SP, julgado em 08/09/2020, "Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos", o que ocorreu no caso em comento.

As circunstâncias, efetivamente, demonstram que a substância ilícita apreendida era destinada à venda: não fosse a admissão informal da mercância e da compra recém realizada a Ivando, não restou comprovado que o réu usaria a balança de precisão com a finalidade específica de conferência da compra adquirida, mesmo porque a quantidade elevada de saquinhos localizados junto com essa substância ilícita desconstituem a versão de que serviam para levá-la para consumo em via pública. Ao mesmo tempo, as fotografias de fls.100/109, não infirmadas, são contundentes e comprovam que o réu se colocava abertamente na internet como vendedor de entorpecente, crédulo da menor fiscalização por parte das autoridades públicas em virtude da situação de calamidade pública, tanto que exibia o seu rosto nas postagens e se utilizava do seu veículo para proceder às entregas pessoalmente, sem medo de ser abordado, ficando, pois, corroborada a denúncia.

Todas as evidências do delito supramencionadas convencem acerca da destinação mercantil do entorpecente e impedem a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos vigente. De se sopesar, ainda, que eventual dependência química não afasta o cometimento do delito, vez que o acusado se pôs a comercializar droga, infringindo a norma. Para a existência do crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/06) não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da venda ou oferta. Com efeito, eventual condição de usuário, mesmo que fosse verdadeira, não enseja a desclassificação pretendida pela defesa, mormente neste caso, em que a traficância está respaldada por provas sólidas e robustas.

Ressalte-se, por oportuno, que, conquanto a quantidade de maconha apreendida não seja expressiva, o tráfico ficou comprovado não só pelo desenrolar da diligência policial e pelos demais elementos probatórios, mas também devido ao depoimento seguro dos dois policiais ouvidos na fase judicial, que enfatizaram a confirmação por Ivando de que comprou a maconha que estava em seu bolso com o réu, cuja embalagem zip lock era idêntica as que estavam na casa deste. No mesmo sentido, tem-se o depoimento de fl.06. Não há nos autos, pois, qualquer fator que exclua o crime ou isente de pena o acusado.

Convém salientar, aliás, que não existe no processo nenhum elemento no qual se possa inferir que o réu ao tempo da ação não tinha capacidade de entendimento e/ou auto determinação com relação ao crime que lhe é imputado.

Destarte, restou comprovado nos autos a prática, pelo réu, do crime previsto no art. 33 "caput", da Lei 11.343/06, na modalidade trazer consigo, manter em depósito e vender substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, conforme a manifestação das partes, não ficou caracterizada a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art.40 da Lei 11.343/06, porquanto não demonstrado que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de local especialmente protegido pela norma. Por conseguinte, não se pode dizer que houve a facilitação da prática criminosa e a disseminação de entorpecentes em área de maior aglomeração de pessoas, estando, desse modo, ausente a ratio legis da norma, a afastar a incidência da majorante em questão.

DA DOSAGEM DA PENA

Diante das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em especial a primariedade do réu, bem como do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, em virtude da situação financeira do acusado.

Ainda, o delito foi cometido durante o estado de calamidade pública, da qual o réu tirou proveito para a prática delitiva, o que impõe o aumento da pena em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, perfazendo, assim, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Saliente-se, ademais, que a admissão da droga apreendida, para consumo próprio, não configura confissão espontânea, não incidindo tal atenuante no caso em tela.

Demais disso, na terceira fase entendo que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo § 4.º do art. 33, da Lei 11.343/06. Denota-se que o réu vinha comercializando a droga fazia algum tempo, aproveitando-se da facilidade das redes sociais para difundir e alavancar suas vendas (fls.100/109). Logo, a dedicação à atividade criminosa ficou delineada, vendo-se que a conduta se repetiu, não sendo a venda a Ivando na data dos fatos a primeira concretizada pelo réu, o que justifica a negativa à minorante em referência.

Desse modo, torno as penas definitivas por inexistirem outras circunstâncias modificadoras.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o SEMIABERTO, dada a quantidade de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por expressa vedação legal (CP, art. 44, I). Da mesma forma, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do sursis.

Por fim, o sentenciado passou a responder aos atos do processo solto, fazendo-se presente na audiência, de modo que poderá recorrer em liberdade, ausentes que estão os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, condeno CRISTIAN PEREIRA BORGES, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando-se sua condição financeira, com os reajustes legais, por incurso no art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 c/c o art.61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais ante o benefício da justiça gratuita ora concedido (fl.211).

Declaro a perda do numerário (fl.90) e objetos apreendidos (fls.12/13), porquanto estes utilizados para a prática delitiva e aquele de procedência criminosa. Expeça-se o necessário.

Atenda-se ao requerido pelo Ministério Público a fls.282/283 para apuração de eventual cometimento de crime de falso testemunho que teria sido praticado por Ivando Lourenço da Silva.

Ciência ao M.P.

P.I.

Araraquara, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA